

1500534-80.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFINITA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO EM ATO INFRACIONAL RELATIVO A TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3243-3944, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500534-80.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Justiça Pública

Réu

PAULO HENRIQUE CRUZ DE OLIVEIRA

CONCLUSÃO

Aos 25 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

PAULO HENRIQUE CRUZ DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14/03/2021, por volta das 21h41min, na Rua Adão Martins, nº 1, Jardim Tatiana, nesta cidade e Comarca de Votorantim/SP, traria consigo e manteria em depósito 01 porção de maconha, com peso líquido de 618,11g, 63 porções de cocaína, com peso líquido de 19,58g, 02 porções de cocaína, com peso líquido de 88,24g, 56 porções de maconha, com peso líquido de 181,67g, 1.738 porções de cocaína, com peso líquido de 544,34g e 30 porções de cocaína, com peso líquido de 2,18g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/02) e a prisão foi convertida em preventiva

(fls. 36/65).

Oferecida a denúncia, com o rol de duas testemunhas, o denunciado foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei n.º 11.343/06 (fl. 115).

A defesa não suscitou preliminares capazes de afastar a imputação constante na denúncia e arrolou testemunhas (fls. 93/97). Outrossim, havendo prova suficiente de materialidade do crime e indícios de que a autoria recaía sobre o acusado, a denúncia foi recebida (fls. 130/131) e o réu, citado (fl. 143).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva de duas testemunhas (fl. 160). Em seguida, o acusado foi interrogado (fl. 161).

As partes apresentaram alegações finais às fls. 160 e 162/167.

O julgamento foi convertido em diligência em razão de o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 119/123 ter apontado que, dentre as substâncias apreendidas, havia lidocaína e cafeína (itens 6 a 9), as quais, contudo, não constaram da denúncia, de modo que, a fim de garantir a ampla defesa do acusado e o exercício ao contraditório, foi determinada abertura de vista ao Ministério Público para avaliar a possibilidade de aditamento da exordial (fl. 168).

A denúncia foi aditada para dar o réu como incurso nos artigos 33, caput, e 33 §1º, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 172/176) e o aditamento foi recebido às fls. 184/185, após manifestação da defesa às fls. 180/183.

A defesa apresentou nova resposta à acusação com relação ao aditamento à denúncia (fls. 189/194) e a preliminar suscitada foi afastada pela decisão de fl. 199.

O réu foi novamente citado à fl. 204.

Em audiência, foram novamente ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 222/223).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia e respectivo aditamento, a exasperação da pena-base, em razão da elevada quantidade e natureza dos entorpecentes e matérias-primas apreendidos, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa e o afastamento da referente à confissão espontânea, pois parcial, bem como pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, em razão da prática de atos infracionais pretéritos (fls. 43/44 e 146/159) e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e matérias-primas, seguida a denúncias, denotarem que o réu se dedicava, com habitualidade e há longa data, a práticas criminosas. Requereu, por fim, a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena (fl. 166).

Já a defesa, reiterando, em sua maior parte, os argumentos deduzidos, às fls. 180/183, quanto ao aditamento da denúncia, bem como suas alegações finais de fls. 162/167, requereu, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade decorrente da entrada dos policiais na residência do réu, supostamente sem autorização. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, pelo reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 em seu grau máximo, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo estabelecimento de regime diverso do fechado para eventual necessidade de cumprimento da pena corporal e pela concessão do direito de o réu recorrer em liberdade (fls. 213/221).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que o flagrante se protraí no tempo, sendo desnecessário, portanto, o mandado citado pela defesa.

A apreensão de entorpecentes e de outras substâncias com o acusado, aliado ao fato de ele ter confessado informalmente aos policiais possuir mais drogas em sua casa – em consonância com a denúncia anônima recebida –, permitia a entrada dos policiais na residência. Ademais, foi afirmado por ambas as testemunhas que a genitora autorizou a entrada na residência, sendo que ela sequer foi arrolada pela defesa para contradizer tal assertiva. Na verdade, nem o próprio o réu se manifestou quanto à suposta falta de autorização dos policiais para entrada em sua residência.

Por fim, quanto às alegações referentes ao aditamento da denúncia, anoto que já foram apreciadas na decisão de fls. 184/185, a qual reitero nesta oportunidade. No mérito, o pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelos autos de exibição e apreensão (fls. 12/16), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 19/30), pelo laudo de fls. 124/127 (frascos vazios), e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 119/123), evidenciador de que a análise de parte das substâncias apreendidas em poder do acusado foi positiva para drogas e parte delas foi positiva para outras substâncias (matérias-primas) comumente utilizadas para se aumentar o volume e a quantidade das porções de entorpecentes, como cafeína (itens 6, 7 e 9 de ambos os laudos) e lidocaína (itens 8 e 9 de ambos os laudos), bem como pelos depoimentos colhidos.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fls. 06/07), o acusado afirmou que nada foi localizado em seu veículo. Não soube informar quem seria o dono dos entorpecentes que estavam em sua residência, esclarecendo apenas que recebia a importância de R\$ 500,00 por semana do traficante para guardá-los em sua casa.

Em juízo (fl. 167 - áudio e vídeo), o réu disse que não tinha drogas consigo nem no carro quando foi abordado. Após tomar ciência sobre as denúncias, os policiais disseram que tinham que ir à sua casa para pegar documentos e localizaram os entorpecentes que ali se encontravam. É usuário e pegou as drogas, pois estava devendo R\$750,00 para o traficante e não tinha como pagar esse valor, estava desempregado. Sofreu pressão e ameaça e disseram-lhe que pagaria a sua dívida guardando os entorpecentes. Foi preso num domingo e, na segunda, completaria duas semanas, pagaria R\$500,00 da dívida e teria que guardar por mais uma semana para pagar os R\$250,00 restantes. Comprava drogas desse traficante e o conhecia havia cerca de dois anos. Também estava guardando petrechos. Seu patrimônio não é condizente com a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Em seu segundo interrogatório, o réu confirmou a versão acima apresentada.

Acrescentou que os policiais lhe exibiram uma foto sua num celular, disseram saber que ele tinha drogas em sua casa e o interrogando confessou que as possuía. Tinha grande quantidade de drogas em sua casa. Não sabia se havia, no meio das drogas, substâncias usadas para a sua fabricação, como lidocaína e cafeína, pois estava apenas guardando, "não sabia se era pura, se tinha mistura" (sic). Não distribuía as drogas. Os flaconetes também não eram seus. Foi a primeira vez que guardou entorpecentes. Estava desempregado, "desandado", estava indo muito à biqueira para pegar drogas e, quando percebeu, estava devendo bastante dinheiro e a única forma de pagar era guardar os entorpecentes. Tinha uma lata que usava como um "cofrinho" para guardar moedas. Acredita que não tinha R\$476,00. Também estava guardando balança e faca.

A testemunha policial militar Ana Carolina Bodelão Santos (fl. 160 - áudio e vídeo) disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante a audiência, citando o seu nome, Paulo. Tinham denúncias anônimas, recebidas através de sistema de inteligência da polícia, de que ele, Paulo, estaria armazenando drogas na casa dele, fazendo a distribuição nas biqueiras do bairro Jardim Tatiana e fazendo o "recolhe" (sic) do dinheiro, utilizando-se do veículo dele, cuja placa também foi informada. Havia recebido as informações pouco tempo antes. Em patrulhamento na data dos fatos, viram o veículo dele no cruzamento da rua Julieta Domingues Santucci e a Rua Adão Martins, onde o abordaram. Encontraram uma pochete, no veículo, contendo uma porção de maconha, uma porção de crack e alguns pinos de cocaína. Informado sobre a denúncia, o réu confessou a prática delitiva e mostrou onde era a sua residência, dizendo que ali haveria mais um tijolo de maconha e mais uma porção de droga. Foram ao local com o apoio de outras viaturas. Na residência, fizeram contato com a mãe dele - apenas ela estava na casa dele -, e ela autorizou a entrada dos policiais. Localizaram o tijolo e a outra porção de cocaína.

Terminando as buscas na residência, uma escada que dava num sótão chamou a atenção dos policiais. Subiram ao sótão e localizaram o restante das drogas, em grande quantidade, que o réu não havia indicado. O réu confessou que essas drogas também eram de sua propriedade. O local é um sobrado, embaixo moravam os familiares e o

acusado morava na parte de cima, sendo que o sótão pertencia à casa dele. O réu disse que um indivíduo de Sorocaba trazia as drogas para ele, mas não forneceu maiores detalhes. Nunca tinha visto o acusado. Na casa, também foram localizados flaconetes vazios, que o réu recebia para embalar os entorpecentes. Tudo que foi encontrado lá foi apresentado à autoridade policial. Seu superior hierárquico gravou, no celular dele, quando pediu autorização da genitora para entrar na casa e ela autorizou.

Em sua segunda oitiva, a testemunha Ana Carolina Bodelão Santos disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante a audiência, citando o seu nome, Paulo. Prestou depoimento no mesmo sentido do acima transcrito, acrescentando que o réu não resistiu à abordagem. Disse que o réu informou que ele iria distribuir as drogas no bairro, "ele pegava na casa dele e distribuía nos pontos de tráfico" (sic). O acusado disse aos policiais que estava recebendo um pagamento mensal para distribuir as drogas no bairro. Somente os policiais presenciaram as buscas no veículo. Seu comandante gravou, com o celular dele, a autorização da mãe para entrada na residência e ela acompanhou as buscas. As drogas encontradas na casa tinham embalagens idênticas às encontradas na pochete. As substâncias a granel estavam junto com as outras drogas em saco plástico, mas não sabe distinguir as substâncias lidocaína e cafeína das demais, "sem muita diferença, as drogas estavam tudo junto, tanto as que estavam preparadas para uso, quanto essas que a granel" (sic). Indagada se saberia dizer se a droga estava "batizada", respondeu que não. Não presenciaram o réu vendendo ou entregando alguma substância.

A testemunha policial militar Giovani Bruno Paiffer Benedito (fl. 160 - áudio e vídeo) disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante a audiência, citando o seu nome, Paulo Henrique. Prestou depoimento no mesmo sentido dos relatos prestados pela testemunha policial Ana Carolina. Acrescentou que também localizaram uma balança de precisão, uma faca com vestígios de "picar" (sic) droga e uma certa quantidade em dinheiro - "estavam bem juntos as coisas lá" (sic). Indagado, o réu disse que recebia dinheiro para guardar as drogas e distribuí-las. A princípio, o réu quis "passar uma parte menor" (sic) das drogas, que estavam no quarto dele, mas depois encontraram as que estavam no sótão. Foram apreendidos um tijolo de maconha, bastantes pinos cheios e muitas embalagens fechadas com pinos vazios, sacolas fechadas com cocaína ainda não separadas, algo que parecia ser pedra bruta de crack, porções de maconha embaladas para venda. Não conhecia o acusado. O depoente gravou o momento em que conversou com a genitora e ela autorizou a entrada na casa. Havia um rapaz, que acredita ser o irmão dele, que também disse para os policiais ficarem à vontade, acrescentando que "já aconteceu isso antes" (sic), "ele já deu problema antes com isso" (sic) e apontaram o quarto do réu.

Em sua segunda oitiva, a testemunha Giovani Bruno Paiffer Benedito disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante a audiência, citando o seu nome, Paulo. Prestou depoimento no mesmo sentido do acima transcrito, acrescentando que o veículo indicado na denúncia era um Corsa Wind, salvo engano prata, e que o indivíduo denunciado se chamava Paulo Henrique, pessoa que não conhecia. Não tem conhecimento técnico para diferenciar lidocaína, cafeína, cocaína apenas olhando. Havia substâncias a granel na residência, em sacolas. Indagado se, além das drogas, localizaram algum produto químico, respondeu que "estavam todas juntas no mesmo lugar, escondido, em diversos sacos, sacos grandes" (sic), eram sacos de lixo. Dentro dos sacos, havia sacolas diversas, com substância branca, dois ou três sacos grandes com bastantes pinos, alguns materiais com papel filme, comumente usados para embalar droga, maconha, dinheiro.

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de tráfico de drogas recai sobre o réu.

Os policiais patrulhavam o local dos fatos, cientes de denúncias anônimas que indicavam o réu como traficante e informavam as placas do veículo utilizado por ele na prática do delito.

Abordaram-no e, em seu veículo, encontraram parte das drogas apreendidas.

O réu negou tal localização de entorpecentes, porém não citou qualquer razão para que os policiais inovassem nessas informações, supostamente alterando a realidade dos fatos.

De posse das denúncias anônimas e recebendo, durante a abordagem, a confissão informal do réu de que ele teria mais entorpecentes em sua residência, dirigiram-se para lá e encontraram o restante das drogas apreendidas, bem como embalagens vazias, balança de precisão, faca com resquícios semelhantes a drogas e dinheiro, apreensões essas em total consonância com o relatado nas denúncias de que o réu seria responsável por armazenar drogas em sua casa e distribuí-las pelo bairro, bem como recolher o dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes.

O réu admitiu que os entorpecentes e petrechos encontravam-se em sua casa, mas tentou justificar a sua conduta, afirmando que os guardava ali para pagar dívida que possuía com o traficante com quem adquiria drogas para seu consumo. Seja como for, o fato de ser usuário de entorpecentes, à vista das provas produzidas, não exime o réu da responsabilidade pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, que é cada vez mais comum por usuários como forma de manutenção de seu vício. Neste sentido:

"INADMISSIBILIDADE - Prova idônea e suficiente à condenação. Dependência que não afasta a condição de traficante. Manutenção do regime inicial fechado (Artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal). Recurso Ministerial e da Defesa parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 0000258-73.2016.8.26.0608; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019).

Importante destacar, conforme apontado pelo Ministério Público, que, segundo os policiais, o réu tentou disfarçar que havia mais drogas em sua residência, a demonstrar que ele tinha conhecimento da existência de uma quantidade maior de entorpecentes no local.

Os depoimentos dos policiais, prestados na fase inquisitorial e judicial, hão de ser prestigiados, pois foram coesos e coerentes entre si e apresentaram contornos de verossimilhança, além de estarem em conformidade com o conjunto probatório, formando um todo harmônico e lógico. Neste sentido:

"É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014)" (AgRg no REsp 1730446/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018).

O acusado não conhecia os agentes policiais e estes não o conheciam e não existe informação de que eles pretendessem imputar-lhe falsamente a prática do crime descrito na denúncia, de modo que nada há nos autos que retire a credibilidade dos relatos por eles prestados. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados:

(...) Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000557-61.2015.8.26.0551; Relator (a): Luís Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 09/01/2020).

Ademais, mister se faz atentar que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, vários fatores devem ser considerados. Dispõe o §2º do art. 28 da Lei 11.343/06: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em apreço, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em poder do réu, junto a petrechos, embalagens vazias e dinheiro, bem como denúncias a apontarem o seu nome e o seu veículo como ligados à prática do tráfico na região, e ainda a confissão informal externada pelo acusado aos policiais durante a abordagem, não são compatíveis com a condição de usuário alegada por ele, mas, por outro lado, permitem concluir que ele praticava a atividade espúria indicada na

exordial. A jurisprudência pátria tem adotado o mesmo entendimento:

"(...) com base na grande quantidade de droga apreendida, o Tribunal de origem concluiu que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 4. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa." (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018.) (AgRg no HC 538.925/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Destaco que o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sendo, pois, despicienda a prova da efetiva venda. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INCIDÊNCIA EM MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. CRIME ÚNICO. CULPABILIDADE ACENTUADA. REGIME INICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente. (HC 468.053/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

Por fim, em que pese a manifestação ministerial pelo reconhecimento do concurso material dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 33, §1º, ambos da Lei nº 11.343/06, este deve ser absorvido por aquele, à luz do princípio da consunção, uma vez que não ficou caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes aptos a vulnerar o bem jurídico de forma distinta; ao contrário, a apreensão se deu no mesmo contexto e as drogas e insumos estavam juntos para serem misturados quando do preparo das porções de entorpecentes a serem comercializados, apresentando-se os insumos, portanto, com o exclusivo fim desse preparo, salvo prova em sentido contrário, que não foi produzida. Neste sentido:

(...) TRÁFICO DE DROGAS, TER EM DEPÓSITO OU GUARDAR MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. POSSE OU GUARDA DE PETRECHOS PARA A FABRICAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. (...) ABSORÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO § 1º DO ARTIGO 33 E NO ARTIGO 34 PELO DO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. (...) 1. Esta Corte Superior de Justiça entende que é possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do artigo 33 e no artigo 34 pelo tipificado no caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. 2. No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora reconheceu que as infrações penais em apreço teriam sido praticadas em contextos fáticos distintos, não havendo que se falar, assim, em aplicação do princípio da consunção. 3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus. Precedente. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MESMO CRITÉRIO NO CÁLCULO DAS REPRIMENDAS REFERENTES A CADA UM DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE TÓXICOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta

social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, o aumento procedido nas penas-bases do paciente em razão da quantidade de droga apreendida em sua residência encontra-se devidamente justificado e não se mostra desproporcional, sendo certo que inexistente qualquer óbice à utilização do aludido critério para incrementar a reprimenda na primeira fase da dosimetria em relação a mais de um delito constante da Lei de Tóxicos, sendo vedado, apenas, o emprego de um mesmo fundamento em mais de uma etapa do cálculo da sanção. Precedente. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334/AM, sob o regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que a natureza e a quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico de drogas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem, cabendo ao magistrado decidir em que momento as utilizará. 2. Na espécie, a autoridade registrou que as circunstâncias em que se deu o flagrante demonstrariam que o paciente se dedicava à atividades criminosas, fundamento que se revela idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Precedentes. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HABEAS CORPUS Nº 346.077 - SP (2015/0322809-9) - Ministro Jorge Mussi - Julgamento 17/05/2016)

HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 34 DA LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva. Doutrina. 2. O crime descrito no 34 da Lei n. 11.343/2006 busca coibir a produção de entorpecentes, enquanto a norma incriminadora do tráfico de estupefacientes possui como objetivo obstar a disseminação dos materiais tóxicos. Sendo assim, nos termos da orientação jurisprudencial desta Casa, necessário avaliar, para fins de incidência do princípio da consunção, a concreta lesividade dos instrumentos destinados à fabricação, preparação ou transformação dos entorpecentes. Precedentes. 3. Na espécie, os condenados, além de terem em depósito certa quantidade de entorpecentes para fins de mercancia, armazenavam, em significativa escala, maquinários e utensílios - balanças, tachos e substâncias para mistura, com peso total, conforme auto de apreensão, de dezenove quilogramas - que não se destinavam somente à preparação dos estupefaciente encontrados no momento da prisão dos réus, compondo, para além disso, laboratório que funcionava de forma autônoma, proporcionando a preparação de número muito maior de substâncias estupefacientes. Desse modo, inviável a incidência do princípio da consunção, porquanto evidenciada a independência entre as condutas, ou seja, a fabricação ou transformação dos materiais tóxicos não operou como meio necessário para o crime de tráfico de entorpecentes. 4. Habeas corpus denegado (HABEAS CORPUS Nº 349.524 - SP (2016/0044140-3) - Ministro Antonio Saldanha Palheiro - Data do Julgamento: 18 de maio de 2017)

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do acusado.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu é primário e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes de fls. 116/118, certidão estadual de distribuições criminais de fl. 43.

Na primeira fase, atenta às chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal e, ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, diante da quantidade expressiva de entorpecentes, lidocaína, cafeína e petrechos, a impor maior reprovabilidade à

conduta do acusado, em 07 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a considerar. A confissão espontânea não há que ser reconhecida, uma vez que foi parcial, conforme fundamentado acima, pois, embora o réu tenha confirmado que mantinha as drogas em depósito, havia denúncias anônimas indicativas de que ele as distribuía e ele tentou ludibriar os policiais, apresentando apenas parte das drogas que estavam em sua residência, sem contar que não confirmou que também foram localizadas drogas no seu veículo. Nesta fase, deve ser reconhecida a circunstância atenuante referente à menoridade relativa do acusado, razão pela qual reduz a reprimenda em 1/6 (um sexto), alcançando 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem consideradas. Embora o acusado seja primário e não possua maus antecedentes, tem apontamentos na Vara da Infância e Juventude (fls. 44, 146/152 e 156/155). Em que pese tais apontamentos não possam ser considerados como maus antecedentes ou reincidência, indicam evidente envolvimento do acusado com a prática de atividades criminosas. Ademais, a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, petrechos, embalagens vazias e dinheiro, seguidas à denúncia anônima já mencionada, reforça tal entendimento, sobretudo porque os objetos representavam expressiva soma em dinheiro, se considerado que cada porção costuma ser vendida a R\$ 10,00, como comumente informado por policiais ouvidos em audiências neste juízo, que não seriam disponibilizados a pessoas iniciantes na atividade espúria. Deste modo, entendo por afastar a possibilidade de redução da pena nos moldes do previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFINA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO EM ATO INFRACIONAL RELATIVO A TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - (...) II - (...) III - (...) IV - (...) V - Nos termos do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. VI - Embora atos infracionais não configurem maus antecedentes ou reincidência, a prática reiterada pelo paciente de condutas relativas ao tráfico de drogas, inclusive com a procedência de uma representação (condenação), impede seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, considerando que tais elementos demonstram que o agente se dedica às atividades criminosas. VII - Ademais, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, ocasião em que o paciente empreendeu fuga em alta velocidade, logrando-se apreender certa quantidade de crack, demonstram, também, a prática reiterada da conduta ilícita. VIII - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando o quantum (5 anos), a primariedade do agente e a inexistência de circunstância judicial desfavorável, adequado o modo semiaberto para o início da expiação, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP. IX - Por ocasião do julgamento do ARE n. 964.246, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário do col. Pretório Excelso reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal" (ARE n. 964.246/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25/11/16). X - Os recursos para as instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias. XI - Não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o Tribunal de Justiça determina a execução provisória da pena, com amparo no novo entendimento do col. Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus não conhecido. Ordem

concedida de ofício, para reduzir a pena-base, sem reflexos na pena definitiva, bem como fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. (HABEAS CORPUS Nº 420.720 - SP (2017/0266511-7) - Quinta Turma do C.Superior Tribunal de Justiça - Relator: Ministro Felix Fischer - Julgamento 05 de abril de 2018).

Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c. art. 33, §3º, c.c. 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei n.º 7.210/84, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Com relação à detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, urge proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado não somente pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias do delito (art. 33, do Código Penal). Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão e acompanhamento do cumprimento da pena aplicada na fase da execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu PAULO HENRIQUE CRUZ DE OLIVEIRA, CPF nº 489.866.268-45, portador do RG nº 56361532, filho de pai JORGE PAULO DE ALMEIDA OLIVEIRA, mãe DANIELA VAZ DA CRUZ, nascido em 07/12/2000, em São Paulo-SP, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime INICIALMENTE fechado -, da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal. Outrossim, à luz do princípio da consunção, ABSOLVO PAULO HENRIQUE CRUZ DE OLIVEIRA, acima qualificado, do delito previsto no art. 33, §1º, da lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o acusado permaneceu preso ao longo do feito e persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, constantemente violada pela prática de crimes como o ora indicado, e o regime inicial de cumprimento de pena imposto, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Neste sentido:

"(...) Inexiste ilegalidade na sentença que manteve a prisão preventiva e negou o recurso em liberdade, pois a constrição antecipada do réu foi mantida em razão da sua periculosidade, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) pela qual foi condenado, a demonstrar a necessidade da garantia da ordem pública". (HC 489.707/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019, grifei).

Recomende-se o réu em estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena ora fixado.

Considerando-se o disposto no art. 91, inciso II, alínea "a" do Código Penal c.c. art. 63 da Lei n.º 11.343/06, declaro a perda dos bens e valores apreendidos em poder do acusado (fl. 12) em favor da União e determino que sejam revertidos em favor da Funad e Senad.

Anoto que foi autorizada a incineração das substâncias apreendidas (fls. 65), providência já tomada pela autoridade policial (fl. 129).

Custas ex lege.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se.

Votorantim, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA